

1523017-69.2022.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 22ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 24/08/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
AUTOR Desconhecido 1 e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

NIKOLAS ALVES DA SILVA foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no art. 157, § 1º e § 2º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, "j", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
22ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523017-69.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1523017-69.2022.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
AUTOR Desconhecido 1 e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

NIKOLAS ALVES DA SILVA foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no art. 157, § 1º e § 2º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, "j", ambos do Código Penal, porque, no dia 24 de junho de 2022, por volta das 18h23min, na Rua Professou Pedro Antônio Pimentel, nº 147, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, em plena pandemia do coronavírus (COVID 19), subtraiu, para proveito próprio, um notebook da marca Compaq e o aparelho de telefonia celular da marca Samsung, modelo Galaxy S20, IMEI 358558825932457, pertencentes à vítima Joziane dos Santos Silva, empregando contra a vítima grave ameaça como forma de assegurar a impunidade a detenção da coisa para si.

Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta Escrita à acusação, sendo proferida decisão saneadora.

Em audiência judicial foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Nos debates, as partes fizeram seus rogos finais.

Autos nº 1522406-19.2022.8.26.0050, referentes à prisão temporária do acusado, e nº 1522392-35.2022.8.26.0050, relativo à busca e apreensão judicialmente autorizada, apensos ao presente processo principal.

É o relatório do quanto necessário.

Condenação de rigor, pese embora reconheça o hercúleo esforço de convencimento da parte do culto Defensor.

Com efeito, dúvida não me paira de, nas condições de tempo e local descritos na Denúncia, o acionado, conduzindo uma motocicleta, abordou a vítima, em via pública, e, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu um notebook e um aparelho celular, partindo em fuga na sequência.

A prova produzida em contraditório se mostrou suficiente e séria (TACRIM, apelação nº 1.038.173/9), a indicar, com significativa certeza moral (Revisão nº 192.804/1, Julgado em 30/08/1.990, 4º Grupo de Câmaras, Relator: - Corrêa de Moraes, Declaração de voto vencedor: - Walter Tintori, RJDTACRIM 8/252), a responsabilidade do réu pela prática do crime em questão, valendo lembrar que o conceito de suficiência, não se confundindo, para efeito condenatório, com isenção total de eiva dubitativa, consiste, pois, na firme possibilidade de afirmação da realidade do fato imputado e de definição de sua autoria, no contexto das comprimidas fronteiras humanas da capacidade de apreensão dos elementos probatórios e de reconstituição do episódio delituoso. Prova suficiente não é e nem pode ser penhor de certeza plena, de que somente os deuses são senhores. Daí que se afigura irreal e meramente retórico o emprego de expressões como "prova categórica", "prova cabal", "prova inconcussa" e outras do gênero (Apelação Criminal nº 1.218.269/2 - rel. Juiz Correa de Moraes - j. 16/08/01 - TACRIM/SP).

Chamada a Juízo para depor acerca dos fatos, a vítima Joziane dos Santos Silva prestou seus esclarecimentos de forma ordenada e harmônica com aquilo que narrou desde o primeiro instante da comunicação dos fatos, ou seja, na data do crime estava no estacionamento, após um dia de trabalho, quando foi tomada de assalto por um indivíduo armado (arma de fogo), que no momento do ataque estava a bordo de uma moto vermelha, sem placas, usando uma blusa de frio preta, e um capacete azul escuro, com detalhes em vermelho. Indicou, inclusive, que este indivíduo a amedrontou com veemência, de forma verbal, tomando seus pertences, saindo em fuga. Prosseguiu informando, ainda, que posteriormente aos fatos, cerca de uma semana, se deparou com seu algoz numa feira livre, se tratando do acionado, ele que estava na posse da mesma moto utilizada no ataque, usando da mesma blusa de frio, afora o mesmo capacete. Tanto que juntamente com colegas fotografou o rapaz e a moto (com o

capacete), que no dia ostentava placas, o que permitiu sua identificação. Bem esclareceu, ainda, que a moto ostentava o mesmo adesivo no paralama, que havia percebido ao momento do assalto. Bem por isso, foi convocada a comparecer na delegacia, onde, então, reconheceu o criminoso, tanto pelos traços de fisionomia, como pela voz, ele que emparelhado a outros dois elementos. Por fim, novamente, reconheceu o acionado em audiência, sem sombra de dúvida, pelos traços de fisionomia, o qual estava emparelhado a outros dois figurantes.

Vale notar que na espécie as declarações da vítima são de grande relevância, porquanto os crimes patrimoniais são marcados pela clandestinidade, sendo reduzido o número de informantes.

Além disso, como não conhecia o réu anteriormente, não teria interesse de prejudicá-lo, de molde que a palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia, pois, ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores, sendo certo que se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações das vítimas, mas, contudo, se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera, sendo certo que a preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta incorreu, e nesta linha não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si (TACRIM-SP-AC- Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

Precisa a ensinança do Desembargador Penteado Navarro, quando da relatoria da Apelação nº 1.440.593-3, ainda quando tomava assento na 5ª Câmara do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, notadamente no tema em questão, oportunidade em que assim decidiu: Ademais, a palavra da vítima merece credibilidade, pois, incidindo sobre o proceder de indivíduos até então desconhecidos, a vítima não teria proveito em mentir e até poderia incorrer no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar os verdadeiros culpados (veja-se, por exemplo, Carl Joseph Anton Mittermaier, Tratado de la prueba em materia criminal, 10. ed., trad. Pedro Aragoneses Alonso, Madrid; Reus, 1979, p. 290-291 e nota 1, ou Tratado da prova em matéria criminal, 3. ed., trad. Alberto Antonio Soares, Ribeiro dos Santos, 1917, p. 403 e nota 12; Nicola Framarino dei Malatesta, Lógica de las pruebas em materia criminal, 2. ed., trad. Simon Carrejo e Jorge Guerrero, Bogotá; Temis, 1978, vol II, p. 143-144, ou A lógica das provas em matéria criminal, trad. Paolo Capitanio, Campinas: Bookseller, 1996, p. 409-410; Eugenio Florian, De las pruebas penales, 3. ed., trad. Jorge Guerrero, Bogotá: Temis, 1990, vol. II, nº 26, p. 70; Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, Da prova no processo penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.994, Cap. XIII, nº 5, p. 111-113; Borges Rosa, Comentários ao Código de Processo Penal, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 1982, art. 201, nota I, p. 310; José Frederico Marques, Elementos de direito processual penal, Campinas: Bookseller, 1997, vol II, nº 496, p. 315; Edgard Magalhães Noronha, Curso de direito processual penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.969, n. 67, p. 120-121; José Lisboa da Gama Marcher, Manual de processo penal brasileiro, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980, vol. I, nº 263, p. 379; Weber Martins Batista, O furto e o roubo no direito e no processo penal, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, XLV, 2, p. 460-463; Julio Frabbrini Mirabete, Código de Processo Penal interpretado, 5. ed., São Paulo: Atlas, 1997, nº 201.4, p. 280. (RT 830/580).

Assim, suas informações em sede de roubo, se mostram, então, vitais, e somente podem ser desprestigiadas com a produção de provas cabais e firmes, a cargo da Defesa, a demonstrar suspeita de comprometimento com a verdade, provas estas que ausentes nos autos.

Note-se que a partir do boletim de ocorrência de fls. 02/03, sua oitiva se deu passados alguns dias, quando, por diligência própria, ao acaso, sem qualquer interferência de terceiro (é dizer, da polícia), bem identificou seu algoz na via, o qual utilizava mesma moto usada no ataque (fls. 10/11), comunicando os fatos à

autoridade policial que encetou diligências próprias para apuração.

Assim, seguiu-se o formal depoimento da vítima (fls. 05), em relato absolutamente alinhado ao informado em Juízo, e acima destacado, tal como o reconhecimento pessoal do acionado (fls. 28), em respeito às disposições do art. 226, do CPP (fls. 38), bem como o reconhecimento de sua voz (fls. 29), do que a vítima bem se recordou ao depor em Juízo.

Não fosse bastante, ainda, reconheceu a moto do acionado, como a mesma utilizada no evento criminoso (fls. 27), sendo importante notar que seja na fase policial, seja em Juízo, a vítima apontou um dístico interessante no veículo, qual seja, a existência de um adesivo no para-lamas do veículo utilizado no ataque, que se evidencia bem na foto da moto do acionado, a fls. 11.

Voltando ao dia do evento, temos, também, as imagens do ocorrido (fls. 06), que malgrado não sejam de boa qualidade, dão conta da abordagem da vítima, às 18:23 horas, por indivíduo em moto, ele que bem se aproxima da vítima, em local com boa iluminação, o que possibilitou a ela, pese embora o criminoso utilizasse capacete, visualizar marcantes traços de sua fisionomia.

Importante destacar que pelas imagens em curso, como disponibilizado às partes no processo, não se pode afirmar, com a segurança que pretende a Defesa, fosse outro o veículo, seus acessórios e capacete utilizado pelo criminoso, que diversos do narrado detalhadamente pela vítima (moto vermelha, capacete azul com detalhes em vermelho, criminoso usando blusa preta), e bem identificados quando ela (vítima) se deparou com o acionado casualmente em feira livre, ele que usava uma blusa preta, esta na posse da moto vermelha com adesivo no para-lamas, e usava um capacete azul marinho com detalhes em vermelho.

E amparando os relatos da vítima, temos, então, o depoimento do policial civil Jorge Braz da Silva, ouvido na qualidade de testemunha, responsável pelas investigações.

Interrogado em solo policial, o réu negou o crime (fls. 42/43), em enredo reiterado na audiência.

Contudo, apresentou discurso fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir.
Triste investida!

Suas testemunhas/informantes, acerca do fato, ou mesmo do álibi apresentado, nada souberam informar de concreto, com segurança a refutar as provas de acusação.

Com efeito, na discussão da presente causa, pretende o acionado informar que ao momento do crime estava em sua residência, com a moto desligada, donde, então, não teria praticado o crime.

De início, bom pontuar que sequer sua mãe, ou seu padrasto, ouvidos na qualidade de informantes, tiveram coragem de, no contraditório, confirmar que na data dos fatos, no horário do crime, o acionado estava na residência comum, na companhia deles, ou de outra pessoa da família com quem convivem. Neste ponto, somente afirmaram que tinham provas de que a moto estava em casa, mas, com convicção, não afirmaram que o acionado estava em casa.

A sua chefe Gisele, dona da lanchonete para a qual prestava serviços, de outra parte, narrou que o acionado trabalha a seu mando, na entrega de refeição (lanche), de terça a sábado, no horário das 16:00 às 23:00 hs, período em que o acionado se apresenta ao trabalho e fica à sua disposição, fazendo uso de moto própria.

É de se destacar, também, que referida testemunha não afiançou que no horário dos fatos o acionado estivesse na residência, no aguardo de seu chamado. Ou seja, pelas suas informações, o acionado estaria à sua disposição, no estabelecimento comercial, como informou no início de seu depoimento, ou, então, fazendo entrega de lanches, exercendo trabalho a que convocado.

Logo, a conversa destacada pela Defesa, a fls. 156, para nada se presta, máxime porque não identificado o dia em que travada.

Por certo, a testemunha Elivania afirma que o acionado fez entrega de seu lanche na data dos fatos, por volta das 18:45 horas, horário que marcou, por se tratar de momento em que sua filha chega na residência, a própria criança recebendo a

entrega. Ainda, afirmou que o local onde se deu o crime, a escola onde trabalhava a vítima, dista de sua residência poucos minutos, tanto que sua filha estuda no local.

Logo, não o afasta da ação criminosa, levada a cabo cerca de vinte minutos antes, em local próximo de sua residência.

Para que não se alegue falta de atenção, o print de fls. 330, também não arreda a identificação de participação do acionado no evento, mostrando, unicamente, conversas possivelmente travadas com ele e terceiros, em momento anterior ao crime, como identificado nas imagens de segurança.

Prossigo!

Ainda atento à tese defensiva, no sentido de que o acusado não poderia ser o autor do crime, haja vista que o rastreador instalado em sua motocicleta apontava, à ocasião dos fatos, estivesse o automóvel em lugar diverso daquele onde cometida a infração, não se sustenta.

Primeiro, porque estranho que dentre os inúmeros documentos acostados pela Defesa, não haja qualquer contrato feito entre o réu (ou pessoa de sua família) e a empresa de rastreamento, que teria sido instalado na moto do acionado.

Segundo, porque o relatório juntado pela defesa a fls. 95/96 não informa o endereço onde apontava o rastreador, sendo, portanto, imprestável.

Terceiro, porque pelo relatório juntado pela defesa a fls. 119/120, o horário mais próximo registrado reporta-se às 18h36min, onde estaria uma motocicleta à Travessa Terra Tombada, Iguatemi, nesta Capital, é dizer, na residência do acionado.

Em breve pesquisa no "Google Maps", é possível obter a informação de que entre o endereço dos fatos e aquele apontado no relatório acima, a distância é de apenas 3,1km, trajeto que pode ser percorrido, de carro, em cerca de 9 minutos, tempo mais do que suficiente para que o réu se deslocasse do endereço onde cometido o crime (por volta das 18h23min) até o local onde sua localização é apontada no relatório (às 18h36min).

Estranhamente, este relatório não faz informação precisa do movimento da moto exatamente no horário dos fatos, o que me toma de assalto. Tampouco revela que a moto estava estanque.

Quarto, porque, pese embora o relatório de fls. 174/229 (em cópia a fls. 230/285), referente a um período de 24 horas, traga alguma indicação de que no horário dos fatos, a moto a que faz referência estaria (ou poderia estar) estacionada, desligada, pondero que referido relatório, como os outros a que me reporte, apresentados pela defesa, não fazem qualquer indicação séria que, realmente, referiam-se à moto do acionado. Interessante que sequer há anotação de que os relatórios se reportam à moto de emplacamento BVW3B73, moto em referência neste processo. De forma simplista, simplesmente se anota tratar de uma moto FAN160, como tantas outras e inúmeras em circulação pela cidade. Bem de ver, ainda, que o acionado registra outra moto em seu nome, consoante verte de fls. 12, afora outra que se mostra em redes sociais, consoante fls. 14.

Portanto, os referidos relatórios apresentados, pese embora o esforço e denodo da Defesa, não se prestam a sustentar o alibi apresentado, de forma a direcionar o convencimento do Juízo na solução absolutória.

De todo modo, a fé que se coloca no rastreador não pode ser tamanha, como pretende a defesa, mormente quando há mensagem extraída do celular do acusado (mediante autorização judicial nos autos nº 1522392-35.2022.8.26.0050), em que NIKOLAS expressamente pergunta à empresa de rastreadores: "Da pra desligar também né", ao que obtém a seguinte resposta "Sim, bloqueia e desbloqueia via app e via SMS (...)" (fls. 34).

Curiosamente, interrogado pela autoridade policial, respondeu que não é possível desligar o rastreador (fls. 42/43) – ao contrário da informação acima colacionada, sobre o que sequer pretendeu incursionar no interrogatório judicial.

Resta, unicamente, a leitura da Defesa técnica, sob sua ótica, de forma a atenuar a questão.

Não bastasse, os documentos de fls. 121/122 em nada afiançam a regularidade do rastreador, não trazendo qualquer informação útil ao deslinde do feito.

Assim, tenho que o relatório de eventos não pode ser tomado de maneira tão

fidedigna quanto pugna a defesa, ante à possibilidade, também, de desligamento do rastreador alocado na motocicleta.

Ainda, corrobora a versão acusatória o áudio extraído do aparelho celular do acusado (link a fls. 35), onde o contato “50tinha” (celular nº 94780-5415) afirma “(...) ainda mais ele, que a moto dele que ele só anda com a moto sem placa, caraio, é raro ver ele ficar de placa (...)”, sobre o que, também, não pretendeu dar explicação idônea.

Ora, por si só, causa bastante estranheza o fato de o réu trafegar habitualmente sem as placas em sua moto, tal como referenciou a vítima em relação a seu algoz. Não bastasse, chamo atenção para o tipo de conversa absolutamente suspeita encontrada no aparelho celular do acusado, que revela, pese embora a primariedade, não se tratar de indivíduo debutante.

Às fls. 37 é possível ver uma imagem da tela do celular do réu, aberta no aplicativo Whatsapp, onde NIKOLAS trava diálogo com um contato denominado “NUNES”, em que o réu indaga “Qual foi a fita” e aquele responde “Pegou nois com as vítima hj”; “Foi em cana nois dois”; “Civil”. Em seguida o réu questiona “Oxi na sua goma?” e obtém a resposta “Foi”, “Nois tava segurando uma vítima da carga aki”, “Ai ele desenrolou no acerto liberou eu”. Posteriormente, ainda na conversa, “NUNES” detalha “Uma vítima d uma carga d quarta feira me reconheceu”, “Civil me pegou aki na rua d casa”, “Eu chegando em cas aí”.

Indagado, quando de seu interrogatório na fase policial, acerca de tal conversa, versando sobre roubo de carga e manutenção de uma vítima em cativeiro, o réu se recusou a responder (42/43). Em Juízo, não se animou a esclarecer.

Neste cenário, dúvida não paira de que, no dia e circunstâncias narradas na Denúncia, o acusado se dirigiu até o local dos fatos e, mediante o grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, visualizada pela vítima, a abordou no estacionamento da escola onde trabalha e subtraiu um notebook e um aparelho celular, partindo em fuga na sequência.

Havendo prova segura da materialidade, tenho, portanto, que a autoria igualmente se confirmou.

Neste cenário, trata-se de crime de roubo consumado, majorado pelo emprego de arma de fogo.

A consumação é evidente e prescinde de maiores incursões argumentativas, especialmente quando os bens subtraídos sequer foram recuperados.

Em tal sentido o entendimento cristalino encerrado na súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

O emprego de arma de fogo também é certo, eis que confirmado pelas declarações seguras da vítima, em Juízo.

Neste sentido, válido registrar que a jurisprudência não exige seja a arma de fogo apreendida para que se reconheça a majorante em foco:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARMA – PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas – artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena quando outros elementos comprovem tal utilização.

Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp

961.863/RS)...o poder vulnerante integra a própria natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência.

Igualmente adequado o reconhecimento da majorante decorrente do emprego de arma (redação da Lei nº 13.654/18), porquanto a vítima foi contundente ao narrar que os roubadores a ameaçavam a todo tempo com o emprego de armas de fogo, até lograrem êxito na subtração de seu veículo. Anoto, neste ponto, que a não apreensão das armas de fogo não tem o condão de afastar referida majorante, que se encontra sobejamente calcada nos contundentes relatos dos ofendidos em Juízo.

No caso dos autos, sobram elementos a consubstanciar o entendimento de que os acusados agiram munidos de arma de fogo, de modo que reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Finalmente, e em arremate, nos termos do art. 383, caput, do CPP (Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.), diversamente do que consta da Denúncia, entendo que não incide no caso dos autos a hipótese do roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal, na medida em que, segundo a dinâmica da ação delitiva, o réu ao abordar a vítima e exigir a entrega dos bens, já o fez mediante grave ameaça, não havendo se falar no emprego desta “a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro”. Assim, responde o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Bem divisada a responsabilidade do acionado, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais não se mostram absolutamente desfavoráveis ao acusado, eis que, pese a gravidade ínsita ao crime praticado, não atuou com dolo superior ao abstratamente previsto pelo tipo penal violado. Assim, fixo suas penas-base no patamar mínimo previsto em lei. Em segunda fase, a circunstância atenuante, decorrente da menoridade relativa do acionado, não o beneficia, nos termos do que determina a súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Revendo posicionamento anterior, me convenço que na espécie não seja o caso de reconhecer a agravante descrita na denúncia (crime praticado durante período de calamidade pública), ausente, na prova, qualquer indicativo concreto de que o acionado se prevaleceu da pandemia para a prática do crime em questão, o que seria imprescindível a render espaço para reconhecimento da agravante.

Confira-se: Agravante prevista pelo art. 61, II, alínea j, do CP não prospera. A situação de calamidade em nada facilitou a ação criminoso, não havendo que se falar em enfraquecimento na proteção do bem jurídico diante do estado emergencial e de aproveitamento do acusado daquela situação. (Apelação Criminal nº 1511782-27.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 18 de março de 2022, rel. Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli)

Ou seja, ausente prova do nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta imputada ao acionado, incomprovado, então, que o acionado tenha se valido de alguma fragilidade ensejada pela pandemia para praticar o crime, seu reconhecimento se mostra impossível.

Sobre o tema, ainda: Habeas Corpus nº 625645-SP, rel. Ministros Félix Fischer; AgRg no Habeas Corpus nº 717.298-SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas; AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior.

Assim, mantenho inalteradas as reprimendas anteriormente fixadas.

Em última fase, ausentes causas de redução de penas, verifico que o crime foi cometido mediante o emprego de arma de fogo, o que faz elevar suas reprimendas em 2/3, na esteira do comando que emerge da Lei.

Penas finais: O cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a

16 (dezesseis) dias multa, fixados no valor unitário mínimo.

O réu cumprirá a pena corporal imposta no regime inicial fechado, por império da Lei, consoante prevê o art. 1º, inciso II, alínea "b", c/c art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.072/90.

Ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu NIKOLAS ALVES DA SILVA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a 16 (dezesseis) dias multa, fixados estes no patamar mínimo previsto em lei, por infringência ao disposto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Conforme insculpido no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Não obstante, tal quantia depende de pedido certo e líquido por parte da vítima, não bastando a alusão genérica a "indenização".

Neste sentido, assevera GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustenta-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa."

Com efeito, no caso dos autos, pese embora o zelo da representante Ministerial, se limitou a pleitear a fixação de "indenização pelos prejuízos que a vítima sofreu em razão do delito" (fls. 71 - Petição Inicial), o que foi reiterado em debates.

Nestes termos, inviável a fixação de indenização mínima, máxime sem qualquer parâmetro que permitisse ao acionado defender-se.

Neste sentido: Apelação Criminal nº 0019874-30.2014.8.26.0050, j. em 23 de abril de 2019, rel. Desembargador Leme Garcia; Apelação nº 0048162-46.2018.8.26.0050, j. em 12 de março de 2019, rel. Desembargador Luís Soares de Mello; STJ, AgRg no REsp 1483846 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Data do julgamento 23/02/2016, DJE 29/02/2016.

Destarte, este pleito fica INDEFERIDO.

Outrossim, ainda se fazem sensíveis os motivos autorizadores da custódia cautelar do acionado, consubstanciados na decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, mais ainda, agora, com a superveniência de condenação a duras penas, de forma que mantenho a custódia do sentenciado, caso pretenda a via recursal.

Com tal providência, garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de agosto de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei
Federal nº 11.419/06